

刑法
No124

H22-8

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、() 内の犯罪が既遂になる場合には1を、未遂にとどまる場合には2を、既遂にも未遂にもならない場合には3を選びなさい。

ア. 甲は、行使の目的をもって一万円札を偽造しようとしたが、印刷機器の操作を間違えたため、出来上がったものは、一般人が一見して真正の通貨と誤認するには至らない程度のものであった。(通貨偽造罪)

イ. 甲は、乙方応接間で乙と雑談中、乙が部屋を出たすきに隣室にある金目の物を探して窃取しようと思い立ち、乙に対し、「お茶が欲しい。」と言って、乙を台所に行かせたが、乙の娘が応接間に入ってきたため、隣室に行くことができなかった。(窃盗罪)

ウ. 甲は、通行中の女性乙に自動車内で暴行を加えて性交する目的で、激しく抵抗する乙を自動車内に引きずり込み、数キロメートル離れた河原まで自動車を走行させたが、乙がすきを見て逃走したため、性交できなかった。(不同意性交等罪) (改)

エ. 甲は、深夜、強盗の目的で会社事務所に入り込み、一人で勤務していた事務員乙を縛り上げ、持参したボストンバッグに同事務所に設置された金庫内の現金を詰め込んで手に持ち、同事務所の出入口から外に出ようとしたところ、駆けつけた警察官に同事務所内で逮捕された。(強盗罪)

オ. 甲は、乙から現金を喝取する目的で、現金の交付を要求する脅迫状を乙宅に郵送したが、乙が不在中に同脅迫状を受け取って読んだ乙の妻が直ちに警察に届け出たため、甲は現金を取得できなかった。(恐喝罪)

No124

H22-8

既遂時期

正解

ア 2

イ 3

ウ 2

エ 1

オ 2

正答率

55%

ア 未遂にとどまる

まず、本記述では、通貨偽造罪（148条1項）における既遂罪の成否が問題となる。通貨偽造罪における「偽造」とは、通貨の発行権を持たない者が、一般人をして真貨と誤信させるような外観のものを作成することをいい（最判昭22.12.17）、製作された物が一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っていることが必要である（最判昭25.2.28）。本記述では、一般人が一見して真正の通貨と誤認するには至らない程度のものであったから、通貨偽造罪の「偽造」には当たらない。よって、通貨偽造罪における既遂罪は成立しない。次に、通貨偽造罪における未遂罪の成否が問題となる。偽造の実行に着手したが、結果として、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至らなければ、未遂罪が成立する。本記述では、甲は、行使の目的をもって、1万円札を偽造しようとしており、通貨偽造罪の実行の着手が認められる。そして、印刷機器の操作を間違えたため、出来上がったものは、一般人が一見して真正の通貨と誤認するには至らない程度のものであった。よって、甲は、偽造の実行に着手し、製作した物が結果として、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至らなかったといえる。よって、通貨偽造罪における未遂罪は成立する。したがって、本記述は、通貨偽造罪の未遂にとどまる。

イ 既遂にも未遂にもならない

まず、本記述では、窃盗罪における既遂罪の成否が問題となる。行為者が財物の占有を取得したときに、窃盗は既遂となる。本記述では、未だ財物の取得をしていない。よって、窃盗罪における既遂罪は成立しない。次に、窃盗罪における未遂罪の成否が問題となる。この点、窃盗罪における実行の着手時期につき、判例は、窃盗罪が成立するには他人の事実上の支配内にある他人の財物を自己の支配内に移すことが必要とされるから、他人の財物を領得する意思に出た行為であっても未だ他人の事実上の支配を侵すにつき密接した程度に達しない場合においては窃盗罪に着手したとはいえない（大判大6.10.11）とし、また、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をしたときは窃盗罪に着手したといえる（大判昭9.10.19）としている。よって、窃盗罪における実行の着手時期は、目的財物に対する他人の占有を侵害する行為を開始した時であるが、実際に目的財物に対する他人の占有を侵害し始めたことまでは必要なく、目的財物の占有を侵すについて密接な行為を開始したことで足りる。そして、どのような場合に侵害行為を開始したといえるかは、当該財物の形状、窃盗行為の状況、犯行の場所等の諸般の状況を勘案して、一般人の通念によれば占有侵害の具体的危険が発生したと評価されるかによって判断する。この点、被告人が電気器具類たる被害者方店舗内において、懐中電燈により店内を照らしたところ、電気器具類が積んであることがわかったが、なるべく金を盗りたいので煙草売場の方に行きかけた際、被害者らが帰宅したという事案において、判例は、「被害者方店舗内において、……煙草売場の方に行きかけた際、本件被害者らが帰宅した事実が認められるというのであるから、原判決が被告人に窃盗の着手行為があったものと認め」られる（最決昭40.3.9、百選I61事件）として、窃盗罪の実行の着手が認められるとしている。また、窃盗の目的で家宅に侵入し、金品物色のためたんすに近寄ったが、財物を得ないうち家人に誰何された事案において、判例は、窃盗の目的をもって家宅に侵入し他人の財物を侵すについて密接な行為、たとえば金品物色のためたんすに近寄るような場合は窃盗の着手であったものである（大判昭9.10.19）として、窃盗罪の実行の着手が認められるとしている。これらの判例においては、金品があると考えられる煙草売場の方に行きかけた段階や、金品が在中するたんすに近寄る段階で、占有侵害の具体的危険の発生が認められている。これらの判例と比較すると、本記述では、乙の娘が入ってきたことで、甲が隣室に行くことはできなくなっており、甲がいまだ金目のものがある隣室に向かってすらいない段階である。そこで、判例において占有侵害の具体的

危険の発生が認められた段階にまだ至っておらず、一般人の通念によれば占有侵害の具体的危険が発生したとはいえない。そうすると、甲は、目的財物の占有を侵すについて密接な行為を開始したとはいえず、窃盗罪の実行の着手は認められない。よって、窃盗罪における未遂罪は成立しない。したがって、本記述は、窃盗罪の既遂にも未遂にもならない。

ウ 未遂にとどまる

まず、本記述では、不同意性交等罪における既遂罪の成否が問題となる。不同意性交等罪の既遂時期は、性交等をした時である。本記述では、乙がすきを見て逃走したため、甲は、性交するに至っていない。よって、不同意性交等罪における既遂罪は成立しない。次に、不同意性交等罪における未遂罪の成否が問題となる。不同意性交等罪の実行の着手は、性交等行為、性交等のための暴行・脅迫等への着手より以前の段階であっても、不同意性交等に至る客観的な危険性が認められる場合には肯定される。本記述では、甲は、自動車という、被害者の逃走が困難な密室空間に無理やり引きずりこみ、河原までの走行を開始することにより被害者の逃走を困難にしている。そして、河原への到着後は特に障害もなく、容易に性交行為に及ぶことができたと考えられる。よって、遅くとも河原までの走行を開始した時点で不同意性交に至る客観的な危険性が認められ、同時点で不同意性交等罪の実行の着手があったといえ、不同意性交等罪における未遂罪が成立する。したがって、本記述は、不同意性交等罪の未遂にとどまる。なお、被告人が、同乗していたAが下車して、被害者女性に近づいて行くのを認めると、付近空地に車をとめて待ち受け、Aが同女を背後から抱きすくめてダンプカーの助手席前まで連行して来るや、Aが同女を強いて性交する意思を有することを察知し、Aと不同意性交の意思を相通じた上、必死に抵抗する同女をAとともに運転席に引きずり込み、発進して同所より約5000メートル西方にある佐波川大橋の北方約800メートルの護岸工事現場に至り、同所において、運転席内で同女の反抗を抑圧してA、被告人の順に性交したが、ダンプカー運転席に引きずり込む際の暴行により、同女に全治約10日間の傷害を負わせた事案において、判例は、「かかる事実関係のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした段階においてすでに強姦〔注：不同意性交〕に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において強姦〔注：不同意性交〕行為の着手があったと解するのが相当である」とし、性交等行為に至る以前の段階での実行の着手を認めている（最決昭45.7.28、百選I62事件）。

エ 既遂になる

本記述では、強盗罪における既遂罪の成否が問題となる。強盗罪は、暴行・脅迫を加えて、他人の財物について、その占有を排し、自己又は第三者の実力支配下に置いた時に既遂に達する。本記述では、甲は、事務所の外に出る前ではあるものの、1人で勤務していた事務員を縛り上げ、持参したボストンバッグに現金を詰めて手に持ち、出入口から外に出ようとしていることから、もはや被害者等に再び財物を取り戻される可能性はないといえる。ゆえに、外に出ようとした段階で、会社の占有を排し、現金を自己の実力支配下に置いたといえる。よって、強盗罪における既遂罪が成立する。したがって、本記述は、強盗罪の既遂になる。なお、被告人等が在宅の家人5人全部を縛り上げ目隠をした後1時間にわたり家内の金品を取出し現金をポケットに入れ衣類等は行李、リュックサックに詰め込み、風呂敷に包み、一部は着込みあるいは懐中したという事案において、判例は、「金品を自己の実力支配内においたことは明かであるから原判決が強盗既遂の認定をしたことは正当である。そして被告人等が右金品を戸外に持ち出す前現場で逮捕されたことは強盗既遂の認定を左右するものではない」（最判昭24.12.3）として、強盗既遂罪の成立を認めている。また、被告人が共犯者等と共に被害会社の事務所に押入り、居合わせた男女事務員の全部を縛って全然抵抗し得ず奪われた物を取返し得ない状態に置き、洋服類は着込み、その他の物は荷造りして持ち出すばかりにしたところを、警察隊に踏み込まれて捕縛されたという事案において、判例は、「上告論旨が通説なりとするいわゆる『取得説』から言って、既に物の支配を取得したと言い得るのであ

り、窃盗罪についてではあるが、盗品が犯行の場所から持出される前に既遂を認定した判例が大審院以来繰返されているのであって……強盗罪についてもこの点は同様であ」る（最判昭 24.6.14）として、事務所の外に出る前の段階における強盗既遂罪の成立を認めている。

オ 未遂にとどまる

まず、本記述では、恐喝罪における既遂罪の成否が問題となる。恐喝罪が既遂となるには、恐喝行為が開始された後、恐喝の結果、相手方が畏怖し、任意に財物を交付し、財物が犯人に移転するという因果関係の存在が必要である。本記述では、未だ財物が甲に移転するに至っていない。よって、恐喝罪における既遂罪は成立しない。次に、恐喝罪における未遂罪の成否が問題となる。本記述では、乙が未だ脅迫状を読んでいないことから、恐喝罪の実行の着手が認められるかが問題となる。この点について、被告人が被害者を恐喝して金員の交付を受けるため、恐喝文書を郵送したところ、被害者方に到達はしたが、被害者の妻が恐喝文書を警察に届け出たため、被害者は恐喝文書を了知することなく、被告人が目的を遂げなかった事案において、判例は、「犯人が恐喝の犯意をもって他人を畏怖させるに足る文書を郵便に付して到達させた場合においては受信人をしてその内容を認識し得べき状態に置き、これにより当該文書は行使されたといえることをもって恐喝罪の実行に着手したるものと云うべく而して如斯状態一旦発生したる以上は犯人の意思に基かざる事由により受信人に於て之を了知することを得ざるに至ると雖も之か為めに所謂不能犯となるものにあらず」（大判大 5.8.28）とし、恐喝文書の郵送の場合、相手方の認識し得べき状態に置いた時に実行の着手があるとしている。本記述では、乙は未だ脅迫状を読んでいないものの、乙宅に郵送されており、乙が認識し得べき状態に置かれているといえる。よって、恐喝罪の実行の着手が認められ、恐喝罪における未遂罪が成立する。したがって、本記述は、恐喝罪の未遂にとどまる。